

1501993-87.2019.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... primário, sequer possui processo em curso por tráfico de drogas. Também inexistente inquérito instaurado no qual o acusado consta como indiciado por tráfico. Na verdade, o suposto envolvimento do réu com a comercialização de drogas decorre única e exclusivamente da afirmação de um transeunte, cuja identidade se desconhece por completo, feita aos policiais que fizeram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501993-87.2019.8.26.0244 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501993-87.2019.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316449/2019 - DEL.POL.IGUAPE, 8292653 - DEL.POL.IGUAPE, 1878/19/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2316449 - 01º D.P. IGUAPE, 1878/19/103 - 01º D.P. IGUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELY FONSECA ORNELAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal c/c art. 41 do Código de Processo Penal, em face de Ely Fonseca Ornelas - qualificado e representado nos autos - imputando-lhe prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia de fls. 51-3 oferecida pelo Parquet:

"(...) no dia 31 de outubro de 2019, por volta da 1h20, na Rua Registro, 187, Rocio, nesta Cidade e Comarca de Iguape/SP, ELY FONSECA ORNELAS trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 5 (cinco) porções de cocaína, pesando

cerca de 13,08g e 09 (nove) pedras de crack, pesando cerca de 9,26g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de constatação preliminar a fls. 08 e auto de exibição e apreensão de fls. 9/10). Segundo apurado, na data dos fatos Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina pela região, após receberem a informação de que o denunciado teria assumido o controle do tráfico de drogas no local. Em determinado momento, avistaram o denunciado e, após a abordagem, localizaram no bolso do denunciado algumas porções de cocaína e de crack.

Ainda, encontraram outras porções amarradas no pescoço e por dentro da blusa do denunciado, bem como o valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) em notas fracionadas.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, a forma como estava acondicionada a droga, aliada a quantia em dinheiro apreendida em notas fracionadas, resta evidente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico ilícito. (...)"

Preso em flagrante, foi decretada a prisão preventiva do denunciado (fls. 54-56).

Recebida a denúncia, determinou-se a citação do acusado (fls. 57-58).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal (fls. 108-109).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 110).

Durante a audiência, colheram-se os depoimentos de duas testemunhas. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Foi deferido o requerimento defensivo para instauração de incidente de insanidade mental do acusado, nos moldes do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal. Na mesma ocasião, porém, o Parquet apresentou suas alegações finais oralmente pugnando pela procedência da pretensão punitiva (fls. 142-147).

Laudo Pericial às fls. 178-185.

A Defesa postulou pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição especial (188-191).

Intimada, a Polícia Civil juntou ofício sobre a divergência entre os laudos definitivos e provisórios (fls. 204-206).

As partes manifestaram-se às fls. 211-212 e 215-217.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da prova pericial.

Da análise dos autos, noto que houve divergência entre os laudos provisório e definitivo. Naquele constou: 9 pedras de crack, pesando 9,26g, e 5 pinos de cocaína com peso de 13,08g. Neste, porém, foi apontado: 9 pedras de crack, pesando 1,26g e 6 pinos de cocaína, pesando 3,26g.

No que se refere à pesagem, a Polícia Civil esclareceu que a divergência decorreu das embalagens plásticas e dos lacres utilizados no momento da elaboração do laudo provisório. No entanto, deixo de abordar a diferença de quantidade.

Tal diferença, porém, não confere nulidade à prova, uma vez que a espécie de entorpecente identificada (cocaína e crack) é a mesma e a divergência entre a pesagem foi devidamente explicada. Em relação à quantidade, a divergência será solucionada em benefício da Defesa.

Tráfico de entorpecentes. Preliminares de nulidades. Alegação de falta de correlação entre denúncia e a r. sentença e cerceamento de defesa por inovação da decisão tendo em vista divergências sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos, constantes no laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo. Inexistência. Tipo penal que engloba diversas condutas típicas, todas elas relativas ao mercado ilícito de drogas. Defesa exercida em sua plenitude.

Denúncia e r. sentença que guardam correlação. Divergência entre os laudos que não prejudicaram o acusado. Ao contrário, a denúncia e a r. sentença considerou a menor quantidade mencionada e a dosimetria da pena não sofreu qualquer alteração considerando a quantidade de droga apreendida. Preliminares afastadas. Mérito. Impossibilidade de absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Testemunhos dos policiais válidos. Local conhecido como ponto de drogas. Réu conhecido dos meios

policiais que não comprovou trabalho lícito, tampouco ser apenas usuário de drogas. Multireincidência, uma delas específica, aliás, que comprova que faz do crime um meio de vida, em especial, o tráfico. Penas e regime adequados. Impossibilidade de substituição da pena corporal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0003662-75.2017.8.26.0066; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)

Por tais razões, REJEITO a preliminar de nulidade da prova pericial. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1-2), pelo boletim de ocorrência (fls. 3-5), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9-10), pelas imagens de fls. 23-4 e pelo laudo pericial (fls. 125-7). Do exame desses documentos, concluo que foram encontrados 9 invólucros plásticos contendo 0,86g de crack e 5 invólucros plásticos contendo 1g de cocaína, cujo uso é proibido em todo território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria é certa.

Durante a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Edson Alexandre Aguiar (PoliciaI Militar) contou que na data dos fatos, próximo ao local, foi informado por transeuntes que um rapaz de blusa vermelha e bermuda estaria traficando no local. Encontraram o rapaz que imediatamente foi abordado, sendo que com ele encontraram as drogas em seu bolso e pescoço, e, ainda, certa quantia em dinheiro. Questionado, o réu respondeu que as drogas se destinavam ao consumo próprio. Ely seguiu todas as ordens dadas e não tentou evadir-se. Conhecia Ely dos meios policiais por uma desavença entre ele e a namorada.

Rodrigo de Castro Carvalho Ribeiro (PoliciaI Militar) disse que no dia dos fatos recebeu a informação de que Ely estaria vendendo drogas próximo ao local onde fazia patrulhamento, sendo que o informante passou as características do indivíduo. Em busca pessoal encontraram porções de cocaína e crack com o acusado. O acusado afirmou que era apenas usuário.

Advertido dos seus direitos constitucionais, o acusado optou por exercer sua autodefesa. Em seu interrogatório, Ely Fonseca Ornelas relatou que no dia dos fatos já havia comprado as drogas, estava com 5kg de cocaína, 9 pedras de crack e 115 reais. Foi até a casa de sua mulher e, depois foi ao bairro do Benjamim, ocasião em que a viatura chegou e parou os dois, sendo que o revistaram. Alegou que as drogas eram para consumo próprio. Antes de ir à biqueira estava com quase 200 reais. Acha que gastou cerca de 70 reais em droga. Disse que no dia dos fatos iria comprar lanche para sua namorada e depois iria se drogar. Afirmou que estava assinando e os policiais o recolheram por esse motivo.

Considerando os depoimentos colhidos na instrução, entendo que o porte do entorpecente apreendido é incontroverso. A dúvida resta sobre a destinação: comércio ou uso pessoal.

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. In casu, cuida-se de réu primário, sequer possui processo em curso por tráfico de drogas. Também inexistente inquérito instaurado no qual o acusado consta como indiciado por tráfico.

Na verdade, o suposto envolvimento do réu com a comercialização de drogas decorre única e exclusivamente da afirmação de um transeunte, cuja identidade se desconhece por completo, feita aos policiais que fizeram a abordagem. Em outros termos: os policiais ouviram falar que o réu estaria vendendo entorpecentes.

No momento da prisão, os policiais não fizeram campana ou presenciaram o Ely efetivamente transacionando drogas com usuários. Igualmente não se encontrou material de endolação, como, por exemplo, balança de precisão.

Ademais, a quantidade de droga apreendida é inegavelmente pequena: 0,86g de crack e 1g de cocaína (em peso líquido).

O réu, por sua vez, em todos os momentos do processo declarou que as drogas eram para uso pessoal.

Nessa linha, considerando a primariedade do acusado, a ausência de investigação pretérita que indicasse o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, a falta de material de ondulação e a pequena quantidade de entorpecente apreendida, reputo haver dúvida razoável sobre a efetiva comercialização de drogas por parte de Ely. Como se sabe, segundo a vertente probatória do princípio da presunção de inocência, incumbe ao Ministério Público demonstrar, além de dúvida razoável, que o réu cometeu a infração penal descrita na denúncia.

As provas produzidas, portanto, revelam-se frágeis, não permitindo o reconhecimento de que o material apreendido efetivamente se destinava à comercialização.

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

A partir desses dispositivos, não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após presidir a instrução do feito, colher as provas necessárias para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da adequada interpretação do art. 156 do Código de Processo Penal e do princípio do *in dubio pro reo*, trago à baila as lições do Professor Afrânio Silva Jardim:

[...] somente a acusação é que alega fatos, atribuindo-os ao réu. Eventual 'alegação' deste, será tão-somente aparente, vez que juridicamente deve ser reputada como mera negação dos fatos alegados na denúncia ou queixa", isso porque, no processo penal, o réu é presumidamente inocente e a dúvida sempre o favorece. Sob tal prisma, não é aplicável de forma automática, no processo penal, a distribuição do ônus da prova regulada no processo civil, de forma a transferir ao acusado o dever de demonstrar sua inocência. Urge que a regra do art. 156 do CPP seja compreendida como "a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 294-312).

Portanto, como o órgão de persecução penal, mesmo após a instrução processual, não logrou êxito em convencer o juízo de que o réu praticou a infração descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de rigor a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, trago à baila precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que, mesmo diante da apreensão de quantidade significativa de droga, acolheu a tese defensiva e não reconheceu a configuração do tráfico.

Apelação - Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) - Sentença que desclassificou a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas - Recurso do Ministério Público - Réus flagrados na posse de 487g de maconha - Desclassificação correta - Quantidade compatível com uso pessoal para os dois acusados - Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância - Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância - Operada, no curso do processo, a desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes, de rigor a proposição de transação penal e de suspensão condicional do processo - Benefícios mais favoráveis, porquanto não ensejam reincidência e Maus antecedentes - Conversão em diligência para que o representante do 'parquet' avalie eventuais

propostas.

(TJSP; Apelação Criminal 1511721-06.2019.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

No mesmo sentido:

TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. Ao ser interrogado em juízo, o réu apresentou versão lógica e coerente, que traduz a impressão de condizer com a realidade. O réu, em juízo, negou a prática delituosa tráfico. Portanto, fato é que os policiais (ou quem quer que seja) não viram o réu realizando qualquer conduta típica da traficância. Apenas apreenderam pequena quantidade de drogas. FALTA DE PROVAS. Assim, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a melhor solução para o caso é a desclassificação da imputação para a modalidade prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, pois, inegável que em poder do apelante foi apreendida parte da droga, porém a mesma se destinava ao seu uso pessoal.

(TJSP; Apelação Criminal 1500342-80.2020.8.26.0633; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021)

Deixo de devolver os autos ao Ministério Público para aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, uma vez que o réu está respondendo pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal nos autos de nº 1500990-97.2019.8.26.0244.

À luz do princípio da individualização da sanção penal (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e do critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

III - DOSIMETRIA

Com relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06, que a culpabilidade apresentada é inerente à reprovabilidade do tipo; o réu não ostenta maus antecedentes; não há provas - laudo elaborado por psicólogo ou por assistente social - capazes de desabonar a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos, as consequências e as circunstâncias não destoam do esperado; embora a natureza da droga merece reprovação, tendo em vista o maior potencial de dependência do crack, a quantidade não se mostra desfavorável. Reconheço a confissão espontânea do réu (art. 65, III, "d", do Código Penal). Não há causas de aumento ou de diminuição.

Logo, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, II, da Lei 11.343/06, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pelo período de 6 (seis) meses, tal como autorizado pelo § 4º do art. 28, pena que torno definitiva por não haver outras circunstâncias que a modifique. A pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para, com fundamento no art. 383, caput, do Código Penal, CONDENAR o réu Ely Fonseca Ornelas como incurso no crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e aplicar-lhe a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços comunitários pelo prazo de 6 meses, nos termos delineados na fundamentação.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Não há falar em detração (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Inviável a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

O réu poderá recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal).

Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser liberado, caso não esteja preso por outro processo.

Custas na forma da Lei.

Determino a destruição da droga, na forma do art. 72 da Lei 11.343/06.
Transitada em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e no cadastro da Corregedoria-Geral da Justiça; (b) oficie-se ao Juízo Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Iguape, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA